

**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC**

Resolución 17413-012 de 2014

FUNDAMENTO PARA PROFERIR FALLO ABSOLUTORIO - Ausencia de ilicitud sustancial.

Se le formularon cargos por haber obtenido un incremento patrimonial al parecer no justificado en el periodo comprendido entre marzo de 2006 y octubre de 2010.

Del análisis bancario se estableció que en la cuenta bancaria a su nombre se depositaron sumas de dinero superiores a los ingresos percibidos y acreditados dentro del proceso, deduciéndose que hizo depósitos por cuantía de \$11.450.097, además por haber adquirido en su haber patrimonial dos vehículos.

La disciplinada fue absuelta debido a que una vez analizado bajo los presupuestos de la sana crítica todo el material probatorio allegado a lo largo de la instrucción, tanto en su fase previa como en la posterior etapa de formulación de cargos, incluyendo en las manifestaciones de la defensa, no encontró el despacho mérito para proferir en contra del disciplinado decisión sancionatoria por las diferencias encontradas en el análisis de recursos frente a gastos, inversiones y disminución de pasivos para el periodo objeto de reproche.

FUENTE FORMAL – Ley 734 de 2002. Artículo 48 Numeral 3°. Incremento patrimonial injustificado

INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO / JUSTIFICACIÓN – Atipicidad

“...el Despacho considera que las explicaciones relacionadas con el movimiento de efectivo en la cuenta de ahorros No. XXX, fueron consistentes con las pruebas documentales y testimoniales incorporadas al expediente, por lo que quedaron esclarecidas y justificadas las circunstancias que dieron origen a las operaciones que quedaban pendientes de explicación al momento de evaluar la investigación.

... Con base en lo precedente se concluye que la argumentación esgrimida en los descargos, es coherente y permite deducir que las operaciones en efectivo y la adquisición del vehículo automotor identificado con las placas CYI-4xx, provinieron de recursos cuyo origen es lícito, por lo que el incremento patrimonial verificado se encuentra justificado, por lo que el cargo también se desdibuja por tales conceptos.”

FUENTE FORMAL –LEY 734 DE 2002, art. 4, 5 y 48.3

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-243

Dependencia:	Subdirección de Investigaciones Disciplinarias
Número de proceso:	1704-01-2012-243
Número y fecha del fallo:	17413-012, del 24 de abril de 2014
Asunto:	Fallo de Primera Instancia
Criterio de Selección:	Fallo absolutorio

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Una vez concluida la investigación disciplinaria tramitada en el proceso administrativo disciplinario número 1704-01-2012-105, el Subdirector de investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC, procede a proferir fallo de primera instancia, conforme a las exigencias del artículo 170 de la Ley 734 de 2002 y de acuerdo a lo que sigue.

CARGO FORMULADO

Mediante Resolución 17406-015 del 23 de abril de 2013, se formuló pliego de cargos, conforme a la siguiente proposición:

Cargo

“A la señora XXXX, identificada con la cédula de ciudadanía No. XXX, se le endilgan cargos por haber obtenido un incremento patrimonial al parecer no justificado en el período comprendido entre el 1 de marzo de 2006 y el 31 de octubre de 2010, ya que como resultado como resultado del análisis bancario efectuado (Véanse los folios 9 y 10) se estableció que en la Cuenta de ahorros No. XXXX del Banco de Bogotá, la cual aparece a su nombre, fueron depositadas sumas de dinero superiores a los ingresos percibidos acreditados dentro del proceso, pues la encartada obtuvo ingresos que fueron consignados para los años 2006 a 2010, por un total de \$121.513.340 y en sus cuentas bancarias aparece depositado un total de \$132.963.437.00 durante el mismo período, deduciéndose por consiguiente que hizo depósitos bancarios que no se encuentran justificados por cuantía de \$11.450.097.

De igual forma, del análisis de Gastos e Inversiones Representativas, se le endilgan cargos por haber obtenido un incremento patrimonial en su favor y de manera directa al parecer no justificado, al adquirir en su haber patrimonial los vehículos RENAULT SCENIC 1.6 MT 1600CC de placas XXX, y FORD ESCAPE de placas XXX, sin que se encuentren determinados y justificados a pesar de lo esfuerzos probatorios a la fecha incoados, los recursos utilizados para ello; transacciones comerciales que en consecuencia la disciplinada está llamada a justificar’. (...)”

CONSIDERACIONES DE INSTANCIA

CASO CONCRETO

La actuación disciplinaria se surtió con el objetivo de establecer la existencia y correlativa responsabilidad por parte de la funcionaria XXXX, en la comisión del ilícito disciplinario contemplado en el artículo 48, numeral tercero, inciso segundo, que describe en su carácter de gravísima la falta del servidor público por el incremento patrimonial injustificado, bien en beneficio propio o de un tercero.

En este contexto es menester enfatizar que el interés del legislador al tipificar la falta, no era el de cuestionar per se cualquier incremento patrimonial, sino aquellos que pudiesen derivar de manera directa de actividades irregulares relacionadas con el ejercicio de la función, generando en consecuencia una ganancia antijurídica.

En el caso en particular, la acusación se centró en torno a dos aspectos puntuales surgidos de la evidencia recolectada durante la fase de investigación, como lo fueron los resultados del análisis financiero verificados a través de los movimientos en efectivo y cuya fuente no resultaba conocida, así como la presencia de inversiones en vehículos derivada del análisis de gastos representativos; inversiones que al momento de la formulación de cargos tampoco reportaban una fuente conocida.

Para un mejor entendimiento es pertinente efectuar el estudio a partir de la verificación de las justificaciones que para cada evento formuló la investigada a través de su defensa, por lo que se procederá a analizar inicialmente lo relacionado con el movimiento de efectivo, para concluir con el estudio de los gastos representativos.

1. Movimiento de efectivo

Con relación al movimiento en efectivo, se pudo establecer que en la Cuenta de ahorros No. XXX del Banco de Bogotá, cuyo titular es la servidora pública investigada, fueron depositadas, dentro del período objeto de investigación, sumas de dinero superiores a los ingresos percibidos, al aparecer una diferencia de \$11.450.097.00.

La cifra en mención, desde el inicio del período objeto de investigación en el año 2006, en el que se registró una diferencia no justificada que ascendió a la suma de \$5.200.000; en tanto que en el año 2007 la diferencia sumó \$5.500.119. Así mismo para el año 2008 se registró una diferencia debido a una consignación que ascendió a \$430.000 y finalmente para la anualidad de 2010, se registró una diferencia por \$319.978, operaciones estas que, se reitera, quedaron registradas en la cuenta arriba reseñada.

Al analizar los descargos, observa el despacho que las consignaciones correspondientes al año 2006, quedaron justificadas en \$4.700.000, si se considera que se pudo establecer que \$2.200.000 correspondieron a consignaciones efectuadas por el señor XXX, padre de XXX, hijo de la

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-243

investigada, para lo cual fueron aportadas las pruebas documentales que acreditaron además del grado de parentesco, las causas de las operaciones.

El remanente, provino de las consignaciones que efectuara XXX desde la ciudad de Buenaventura, las cuales fueron explicadas por el depositante en diligencia de testimonio, al plantear que las mismas obedecieron a un favor personal por parte de la investigada, quien prestó la cuenta de ahorros para poder trasladar dineros al padre del testigo quien reside en la Ciudad de Santa Marta. Estas explicaciones efectuadas en diligencia bajo juramento, son recibidas por el despacho, habida cuenta que la explicación es razonable y que no fueron detectadas inconsistencias que hicieran dudar de su credibilidad, por lo que el testimonio debe ser tenido en cuenta.

Finalmente, existe un remanente por \$500.000, consistente en un depósito efectuado el 16 de mayo de 2006 en la ciudad de Bogotá y que la investigada a través de su defensa adujo desconocer su origen. Sobre el mismo, valga la pena indicar que el Despacho requirió a la entidad financiera para que remitiera los soportes que sobre dicha operación reposara en sus registros. La entidad remitió la información sólo hasta el 5 de marzo del año en curso y fue recibida por la Agencia el 11 de marzo, en curso con el período de traslado, pudiéndose constatar la copia del cupón de depósito tal y como obra a folio 922.

Con base en esta información, resulta imposible determinar con claridad la naturaleza y origen de la operación, habida cuenta que no se pudo determinar la identidad del depositante, circunstancia que se suma al hecho de que por el monto de la consignación, no es factible deducir de manera expresa, la consolidación efectiva de un incremento patrimonial y mucho menos que de haber sido incremento, éste se encontrase injustificado. Por tal motivo y ejercicio del principio de presunción de inocencia y de la incertidumbre generada por la imposibilidad de determinar probatoriamente el origen de la operación, el Despacho considera procedente no considerarla, en sede de esta instancia, como incremento patrimonial.

En el año 2207, los depósitos acreditados a la cuenta de la investigada y cuyo origen no había sido esclarecido, ascendieron a \$5.500.119. De esta suma se demostró que \$5.000.000, correspondieron al desembolso del crédito número XXX por \$5.308.394, efectuados por FEPDIAN. El efectivo se representó mediante el giro del cheque No XXX de abril 17 de 2007, el cual fue cobrado por la investigada y la suma de \$5.000.000, fue consignada en la cuenta por XXX, tal y como lo comprueban los documentos pertinentes, que obra a partir del folio 840 hasta el folio 845.

Los \$500.119 restantes correspondieron a una consignación fechada el 24 de mayo de 2007, por valor de \$300.000 como parte de los ingresos percibidos por concepto de arrendamiento de un Apartamento en el Parque Central Bavaria y que ascendía a la suma de \$550.000, para esa época, La consignación fue realizada por XXX, quien en testimonio reconoció que le prestaba servicios de mensajería a la investigada, razón por la cual algunas consignaciones efectuadas a la cuenta de aquella podían aparecer con su rúbrica.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-243

Finalmente, para el 14 de diciembre de 2007, fue registrada una consignación por valor de \$200.119, correspondientes a una comisión efectuada en el Municipio de Maicao, por lo que fueron aportadas las copias de la orden de pago, la resolución que ordenó la comisión y el cumplimiento de la misma tal y como se evidencia a partir del folio 849.

En este orden de ideas, encuentra el Despacho que los depósitos realizados en el año 2007 a la cuenta No. 5641564xx del Banco de Bogotá, quedaron suficientemente soportadas y justificadas.

Con relación al remanente derivado de las consignaciones efectuadas a favor de la investigada en los años 2008 y 2010 y que ascendieron respectivamente a las sumas de \$430.000 y \$319.978; pudo demostrarse que se originaron en una consignación efectuada por XXX, quien para la época era el compañero permanente de la investigada y cuyo objetivo fue el de cubrir gastos derivados de la convivencia, tal y como aparece en la copia de la declaración juramentada de bienes y rentas aportada con los alegatos finales (folios 951 y siguientes), por lo que esta operación es consistente con la argumentación esgrimida por la defensa en torno a que la consignación no puede considerarse como incremento patrimonial injustificado, debido a la relación de convivencia que trae implícitos gastos y operaciones económicas conjuntas.

Finalmente se demostró que la consignación por \$319.978, provino de devolución de una cuota de crédito realizada por el Fondo de Empleados y Pensionados de la DIAN, Seccional Santa Marta, el 6 de octubre de dicha anualidad, por lo que se incorporaron los soportes pertinentes.

Bajo estas condiciones, el Despacho considera que las explicaciones relacionadas con el movimiento de efectivo en la cuenta de ahorros No. XXX, fueron consistentes con las pruebas documentales y testimoniales incorporadas al expediente, por lo que quedaron esclarecidas y justificadas las circunstancias que dieron origen a las operaciones que quedaban pendientes de explicación al momento de evaluar la investigación.

2. Gastos representativos

Con relación a los Gastos Representativos derivados de la adquisición de los vehículos identificados con las placas XXX fue explicado lo siguiente:

Con relación al vehículo identificado con las placas XXX, fue indicado que éste bien fue adquirido por la investigada junto con su hermana XXX en el año 2002, siendo prueba fundamental de esta operación, la copia de la factura expedida el 27 de diciembre de 2002 por el Concesionario Tayrona Motors Ltda en la ciudad de Santa Marta (folio 865), entre otros documentos como el Certificado de Tradición expedido por la Secretaría de tránsito de Santa Marta.

Con este soporte queda corroborado que la adquisición sé realizó antes del período objeto de investigación, por lo que queda excluido del análisis habida cuenta la consonancia que debe existir entre el período fijado en la indagación preliminar, el pliego de cargos y el fallo, por lo que esta operación no debe ser considerada en sede del fallo de instancia.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-243

Con relación al vehículo marca Ford Escape, Placas XXX, la adquisición fue efectuada el 20 de mayo de 2010 por un valor de \$45.000.000, mediante un contrato suscrito con ESPERANZA JUDITH MOLINA CASTRO (folio 873). El pago inicial ascendió a la suma de \$10.000.000 en mayo 3 de 2010, fecha en la que fue suscrito el contrato, recursos que provinieron de la venta que realizara la investigada y su hermana del automotor Renault Scenic modelo 2003, identificado con las placas QFD-424, siendo comprador el señor OSMAN ENRIQUE PALMERA TORRES. Prueba de esta transacción lo es el contrato de compraventa (folio 872) y copia del RUNT donde se registra la tradición del vehículo (folio 864).

La suma remanente, es decir \$35.000.000, provino de dos fuentes principales: \$19.990.400 que correspondieron a un desembolso efectuado por el Banco de Bogotá el 29 de junio del mismo año y cuyo soporte se verifica en la copia del extracto que obra a folio 289; en tanto que el remanente, en cuantía de \$10,009.600, provino de recursos propios correspondientes a salarios ahorrados, conforme se deduce de la lectura de, por lo menos, los extractos de 2010 (folios 288 y siguientes); fuente que determina el origen del pago final por \$5.000.000 en noviembre de ese año, habida cuenta que a folio 291 es registrado un retiro por \$13.500.000, el cual es concordante con el cronograma de pagos pactado con la vendedora en el otro sí suscrito con la vendedora el 23 de mayo de 2010, tal y como obra a folio 874.

Con base en los fundamentos probatorios arriba reseñados, resulta factible realizar una lectura integral de los movimientos efectuados para la adquisición del automotor, vislumbrando que existe coherencia en torno a la fuente de los recursos que fueron utilizados para dicha negociación. Ello permite inferir que el origen de los medios fue legítimo y que no resulta posible plantear la presencia de una actividad que estuviese enmarcado dentro de un incremento irregular del patrimonio de la investigada.

Con base en lo precedente se concluye que la argumentación esgrimida en los descargos, es coherente y permite deducir que las operaciones en efectivo y la adquisición del vehículo automotor identificado con las placas XXX, provinieron de recursos cuyo origen es lícito, por lo que el incremento patrimonial verificado se encuentra justificado, por lo que el cargo también se desdibuja por tales conceptos.

En consecuencia, la decisión jurídica acorde con este planteamiento, no puede ser otra que la de ABSOLVER a la investigada XXXX y en consecuencia archivar esta actuación.

En mérito de lo expuesto, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias,

RESUELVE

PRIMERO: ABSOLVER a XXXX, del cargo a ella formulada mediante auto número 17406- 015 del 23 de abril de 2003, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a la apoderada de la investigada. La citación podrá ser remitida a la Carrera XXX, oficina 505 de la Ciudad de Bogotá.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-243

TERCERO: En firme la presente decisión, comunicarla en la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE y CÚMPLASE,

JORGE ADRIANO MORENO PONCE

Subdirector Investigaciones Disciplinarias -ITRC
Director del Proceso

P- YLAG-NOYR
R- AFVU